“多事的旁观者”检验

英格兰合同法 | Officious bystander test | 依事实默示与不言自明

设想有一位旁观者打断合同谈判，提出后来发生争议的那项具体条款。从订约时的客观情境看，双方是否都会认为早已不言自明？这就是麦金农法官在 Shirlaw 案中所作的设想。

一、先解释明示合同

结合合同语境理解文字。拟议的义务可能已经包含在明示条款中。如果仍有空缺，应明确加入这项条款会改变什么，以及现有合同如何分配相关风险。

这一检验针对依事实默示的条款。源于成文法、惯例或合同类型的条款，各有其适用条件。

二、把旁观者的问题问具体

向双方提出同一项具体条款。谁应在何时做什么？有哪些限制？如果争议涉及访问权限、时间或费用，仅说“双方应当合作”就过于笼统。旁观者的提问是检验工具，关键在于双方是否都会回答“当然！”。

三、以订约时的情形判断是否不言自明

根据合同和当时可获得的背景信息，从处于双方地位的理性人的角度判断。这项条款必须在客观上对双方都显而易见。事后一方声称自己期待有该条款，本身证明力有限。如果双方很可能还要就条款范围协商，就难以认定它不言自明。

四、适用严格的标准

根据 Marks and Spencer v BNP Paribas 案，商业实效（business efficacy）与不言自明是两条可分别适用的路径，通常会得出相同结论。应判断条款是否为合同实际运作所必需，或是否不言自明。拟议条款还须能够清楚表述，并与明示条款相容。单凭公平或便利不足以加入条款。

> 法律英语 | **Officious** 指擅自插手。**It goes without saying** 意为不言而喻。

四个判例及其启示

Shirlaw v Southern Foundries | 固定任期

谢洛被任命为董事总经理，任期十年。公司章程修改后，他被免去董事职务，因而无法继续担任总经理。上诉法院认定，可以默示一项条款，以防约定任期以这种方式提前终止。麦金农法官问的是，双方在订约时会怎样回应这项建议。

The Moorcock | 合同如何在实践中运作

一艘使用码头的船在退潮时触及河床而受损。上诉法院认定，码头方应尽合理注意查明泊位是否安全，并在适当时警示危险。这项义务使约定的码头使用得以实现。它的范围小于对安全的绝对保证。

Marks and Spencer v BNP Paribas | 条款详尽的租约

商业租户预付租金后行使了提前终止权，要求退还租约终止后那段期间的租金。最高法院拒绝加入默示退款条款。没有该条款，租约仍然能够运作。退款看起来公平，本身不足以证明该条款有必要或不言自明。

Barton v Morris | 经协商确定的条件

双方约定，房产按约定价格售出时，中介可获得报酬。实际售价较低。最高法院多数法官拒绝在这一情形下默示合理报酬条款。判断拟议条款时，必须考虑明示约定如何分配风险。

> 判例对照 | 比较 The Moorcock 案中范围有限的义务，与 Marks and Spencer 案中要求退款的条款。没有拟议条款时，合同如何运作？

案例练习与参考资料

调试测试所需的访问权限

一家工厂聘请工程师在预定的两天停机期内测试已安装的传感器。签署的文件写明测试项目及报酬。双方都知道，只有工厂能发放测试所需的临时登录凭证，而且没有其他访问方式。工程师及时提出请求，工厂以合同未提到登录权限为由拒绝。是否可以默示一项条款？

参考分析

把条款限定在必要范围内。 工程师及时提出请求后，工厂应在停机期内提供完成约定测试所合理需要的临时访问权限。工厂的日常安全规则仍然适用。

从双方订约时的角度判断。 约定的测试和固定时段有力地表明，提供访问权限对双方都理所当然。没有权限，工程师无法按计划完成工作，也支持商业实效上的必要性。永久访问权限或访问无关数据则须另有依据。

核查明示条款。 查找安全条件、访问程序或分配拒绝访问风险的条款。然后将工程师的请求和工厂的答复与具体义务相比较。

> 变式 | 合同明确允许工厂拒发登录凭证，并规定可以改用现场监督下的测试。默示发放凭证的义务会与明示约定冲突。

判例选读

Shirlaw v Southern Foundries (1926) Ltd [1939] 2 KB 206, 227 | 麦金农法官的检验
The Moorcock (1889) 14 PD 64 | 第22段引述原判
Marks and Spencer plc v BNP Paribas [2015] UKSC 72, paras 14–31 | 现代判断标准
Barton v Morris [2023] UKSC 3, paras 19–37 | 明示风险分配